NATURALEZA JURÍDICA DE LA CASACIÓN
Sumilla. La casación exige la precisión de las razones y causales que la motivan, en tanto este medio impugnatorio solo se ocupa de determinar si el fallo contiene una violación de la ley y no permite, *per se*, la intervención del Tribunal de Casación para sustituir en la valoración de la prueba al Tribunal de Apelación, a efectos de dictar un fallo sustutivo.

AUTO DE CALIFICACIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho

AUTOS y VISTO: el recurso de casación interpuesto por **Alberto Gómez De la Torre Pretell** contra la resolución de vista del siete de mayo de dos mil dieciocho (foja doscientos uno), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura de la Corte Superior de Justicia de Piura, que por mayoría revocó la resolución de primera instancia del ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la que declaró tener por comprendido como actor civil al recurrente, en la investigación seguida en contra de Medardo López García por el delito de fraude procesal. Al reformarla se le excluyó como actor civil en el presente proceso.

Intervino como ponente el señor juez supremo **Figueroa Navarro**.

CONSIDERANDO

Fundamentos del recurrente

PRIMERO. La defensa de **Alberto Gómez De la Torre Pretell** interpuso recurso de casación excepcional invocando el numeral cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal, vinculándolo con las

causales contenidas en los numerales tres y cinco del artículo cuatrocientos veintinueve del citado Código Adjetivo. De este modo, propuso el siguiente tema:

> La Corte Suprema de la República debe establecer parámetros jurisprudenciales para la uniforme interpretación de los artículos noventa y cuatro y noventa y ocho del Código Procesal Penal, en especial si se puede constituir en actor civil un perjudicado que no sea el titular del bien jurídico penalmente protegido.

SEGUNDO. Por otro lado, en consonancia con las causales invocadas, precisó y desarrolló los siguientes puntos:

i. En cuanto a la causal número tres, en la resolución de vista se ha dado una errónea interpretación de la figura jurídica de actor civil, reconocida en los artículos noventa y cuatro y noventa y ocho del Código Procesal Penal. En concreto, en la citada resolución se precisa que solamente la víctima u ofendido son quienes pueden constituirse en actor civil. Se considera erróneamente que al ser el Estado el titular del bien jurídico protegido por la comisión del delito de fraude procesal, solamente este sea el legitimado para constituirse como actor civil y no un particular concretamente perjudicado por la comisión del delito.

ii. Respecto a la causal número cinco, se indica que la resolución de vista se ha apartado de la doctrina jurisprudencial establecida en el acuerdo plenario número 05-2011/CJ-116.

DERECHO DE PLURALIDAD DE INSTANCIAS

TERCERO. El derecho a la pluralidad de instancias forma parte del debido proceso y goza de reconocimiento nacional e internacional. Así, por un lado, la Constitución Política del Estado, en el artículo ciento treinta y nueve, numeral seis, reconoce a la pluralidad de instancias como un principio de la función jurisdiccional. Y, por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo ocho, numeral dos, literal h, ha previsto que toda persona tiene el "[…] derecho de recurrir […] el fallo ante juez o tribunal superior […]".

CUARTO. No obstante, como todo derecho fundamental, la pluralidad de instancias no es absoluta, sino que está sujeta a limitaciones legales. Así, lo expuesto se ajusta a lo establecido por el Tribunal Constitucional[1], en cuanto el derecho a los recursos es un derecho de configuración legal, es decir, que corresponde al propio legislador determinar en qué casos cabe la impugnación. De modo tal que solo corresponde promover un recurso contra las resoluciones que así lo indique la ley, de manera expresa y bajo las condiciones debidamente señaladas.

QUINTO. En consonancia con la naturaleza de derecho público y tutelar del derecho procesal penal, las normas que regulan esta disciplina son irrenunciables o imperativas, y de garantía. Son irrenunciables porque vinculan a todos los que intervienen en el proceso, sin ser posible sustituirlas por actos jurídicos voluntarios regidos por el principio de autonomía de la voluntad, pues el proceso penal no puede regularse al margen de la ley. Por otra parte, serán de garantía porque tutelan la jurisdicción penal, esto es, definen los presupuestos del ejercicio de la acción penal, explicitan los efectos de las resoluciones judiciales en cada

[1] Ver STC N.° 01243–2008–PHC/TC, del uno de setiembre de dos mil ocho.

caso concreto y regulan la forma y contenido de la actividad jurisdiccional [2].

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

SEXTO. El recurso de casación es un recurso extraordinario y limitado, pues su procedencia debe ser verificada por las causales taxativamente previstas en la ley, cuyo ámbito de aplicación comprende el correcto empleo del derecho material, la observancia de las normas del debido proceso y la producción de doctrina jurisprudencial que unifique los criterios de los tribunales de justicia.

SÉTIMO. En ese sentido, los supuestos de procedencia del recurso de casación se encuentran regulados en el artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal, uno de estos es la casación excepcional. En efecto, el numeral cuatro del citado artículo brinda la posibilidad a las partes de que propongan a la Corte Suprema temas que, más allá del interés que estas pudieran tener sobre la causa en concreto, sean de interés para el desarrollo puntual de la doctrina jurisprudencial. Así, tal como la Corte Suprema ya ha declarado (Queja NCPP N.° 66-2009-La Libertad), existen dos grandes supuestos que justifican la existencia de desarrollo de doctrina jurisprudencial:

i. Necesidad de unificar interpretaciones contradictorias; afirmación de la inexistencia de una línea jurisprudencial o de jurisprudencia vinculante de la máxima instancia judicial, frente a decisiones contrapuestas emitidas por tribunales inferiores; y la definición de un sentido interpretativo a una norma reciente o escasamente invocada, pero de especiales connotaciones jurídicas.

[2] SAN MARTÍN CASTRO, César. *Derecho Procesal Penal*. Segunda edición actualizada y aumentada. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2003, p. 24.

ii. Obtención de una interpretación correcta de normas específicas de derecho penal y de derecho procesal penal. A ello hay que agregar que esta interpretación debe ser de un interés general y no solo de la colectividad de las partes. Cabe resaltar que estos supuestos son meramente enunciativos, no vinculantes, pues podría existir algún otro supuesto no mencionado, que podría ser alegado como justificación para el desarrollo de doctrina jurisprudencial.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

OCTAVO. Así, conforme al recurso de casación excepcional interpuesto, se aprecia que el tema propuesto está dirigido a que se dé una debida interpretación de los artículos noventa y cuatro y noventa y ocho del Código Procesal Penal, específicamente, si se puede constituir en actor civil un perjudicado que no sea el titular del bien jurídico penalmente protegido. Al respecto, el recurrente precisa que en el caso concreto, si bien puede afirmarse que el Estado es el titular del bien jurídico protegido por el delito de fraude procesal, no puede desconocerse que también pueden existir perjudicados por las consecuencias del acto delictivo. Acota que esto se encuentra reconocido en el artículo noventa y cuatro del Código Procesal Penal, que señala que no solamente puede constituirse como actor civil el directamente ofendido por el delito, sino toda persona perjudicada por la comisión del hecho ilícito. En armonía con ello, el artículo noventa y ocho del Código Procesal Penal establece como premisa inicial que el actor civil es el titular de la acción reparatoria y precisa que esta acción solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito.

NOVENO. Ahora bien, en cuanto a la constitución del actor civil, el acuerdo plenario número 5-2011/CJ-116, del seis de diciembre de dos mil once, ha definido conceptualmente lo que es un actor civil (fundamento jurídico décimo primero) precisando que:

> Se define al actor civil como aquella persona que puede ser el agraviado o sujeto pasivo del delito, es decir quien directamente ha sufrido un daño criminal y, en defecto de él, el perjudicado, esto es, el sujeto pasivo del daño indemnizable o el titular del interés directa o indirectamente lesionado por el delito, que deduce expresamente en el proceso penal una pretensión patrimonial que trae a causa de la comisión de un delito [sic].

Dicha definición guarda relación con lo señalado en el numeral uno del artículo noventa y cuatro del Código Procesal Penal, en el que se precisa que se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo.

DÉCIMO. Así mismo, el citado acuerdo plenario ha llegado a interpretar el artículo noventa y ocho del Código Procesal Penal conforme se deprende del fundamento jurídico décimo primero al décimo quinto. Por tanto, en el caso que nos ocupa, los artículos cuya interpretación se requiere ya han sido abordados por el citado acuerdo, cuyos criterios han sido establecidos como doctrina legal, de conformidad con el vigésimo primer considerando. Es por tal motivo que, a juicio del recurrente, se sostiene que la resolución de vista se ha apartado de la doctrina jurisprudencial establecida en el mencionado acuerdo plenario. Esto es, no se discute lo allí establecido, por el contrario, coincide con los fundamentos expuestos en el acuerdo.

DECIMOPRIMERO. Por otro lado, en el tema planteado también se solicitó un pronunciamiento respecto a si se puede constituir en actor civil un

perjudicado que no sea el titular del bien jurídico penalmente protegido. Ello en la medida que el recurrente, en el presente proceso, solicitó se le constituya en actor civil, lo cual fue concedido en primera instancia, mediante resolución del ocho de diciembre de dos mil diecisiete (foja ciento treinta y seis); sin embargo, al ser apelada por el Ministerio Público y el encausado, el Colegiado Superior, por mayoría, revocó la mencionada resolución y excluyó al recurrente como actor civil en el proceso penal por delito de fraude procesal. El fundamento básico se circunscribió a que, en el delito de fraude procesal, el agraviado solo es el Estado y, por tanto, es el único para constituirse en actor civil, en la medida que a quien se pretendió inducir a error, en el caso concreto, fue al juez. Por lo que es correcta esta interpretación.

DECIMOSEGUNDO. Si bien el proceso penal por el delito de fraude procesal se inició con motivo de que el recurrente fue querellado por el encausado Medardo López García –proceso de acción privada en el que este último presentó como medio probatorio (que acreditaría la supuesta calumnia y difamación agravada) volantes que fueron repartidos el dieciocho de junio de dos mil quince–, se quiso con ello inducir en error al juez de la causa. Esa querella luego fue sobreseída y ocasionó perjuicio en el accionante, tal como lo señala en su escrito de constitución en actor civil (fojas uno); sin embargo, en el delito de fraude procesal, por principio de legalidad, solo el funcionario o servidor público es el sujeto pasivo de la acción. De ahí que si el recurrente sostiene haber sido perjudicado por habérsele interpuesto una querella que le ocasionó gastos por la suma de veintiocho mil setecientos treinta y ocho soles con veinte céntimos, ello no implica, *per se*, que sea perjudicado en el delito de fraude procesal, en tanto el tipo penal exige que el sujeto pasivo sea un sujeto especial (funcionario o servidor público), que tiene abierta la

posibilidad de plantear una demanda en la vía civil por responsabilidad extracontractual a fin de que pueda ser resarcido, si el caso lo amerita, por los daños ocasionados. Por tanto, la casación planteada ha de ser desestimada.

COSTAS PROCESALES

DECIMOTERCERO. El numeral dos del artículo quinientos cuatro del Código Procesal Penal establece que las costas procesales serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito. Las costas se imponen de oficio, conforme al numeral dos del artículo cuatrocientos noventa y siete de la norma procesal acotada. Por tanto, le corresponde a **ALBERTO GÓMEZ DE LA TORRE PRETELL** asumir tal obligación procesal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. NULO el concesorio contenido en la resolución número once del veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (foja doscientos veintitrés); e **INADMISIBLE** el recurso de casación excepcional interpuesto por **ALBERTO GÓMEZ DE LA TORRE PRETELL** contra la resolución de vista del siete de mayo de dos mil dieciocho (foja doscientos uno), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura, de la Corte Superior de Justicia de Piura, que por mayoría revocó la resolución de primera instancia del ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la que declaró tener por comprendido en actor civil al recurrente en la investigación seguida en contra de Medardo López García, por el delito de fraude procesal. Al reformarla se le excluyó como actor civil en el presente proceso.

II. CONDENARON al recurrente **ALBERTO GÓMEZ DE LA TORRE PRETELL** al pago de las costas procesales correspondientes, que serán exigidas por el juez de investigación preparatoria correspondiente, de conformidad con el artículo 506 del Código Procesal Penal.

III. MANDARON se transcriba la presente Ejecutoria Suprema al Tribunal Superior de origen y se notifique a las partes.

IV.- DISPUSIERON se devuelvan los actuados al órgano jurisdiccional de origen. Hágase saber y archívese.

S. S.

LECAROS CORNEJO

FIGUEROA NAVARRO

QUINTANILLA CHACÓN

CASTAÑEDA ESPINOZA

PACHECO HUANCAS

FN/ulc.

La parte procesal afectada por un delito de fraude procesal no puede constituirse en actor civil
Comentario a la casación n.º 785-2018-Piura

Percy García Cavero
Profesor ordinario principal de la Universidad de Piura
https://laley.pe/art/8591/la-parte-procesal-afectada-por-un-delito-de-fraude-procesal-no-puede-constituirse-en-actor-civil-comentario-a-la-casacion-n-785-2018-piura
Miércoles, 25 de septiembre de 2019

El autor cuestiona que en una reciente decisión de la Corte Suprema (Casación N° 785-2018-Piura) se haya confundido la calidad de ofendido (titular del bien jurídico) con la calidad de perjudicado (el que sufre un perjuicio por el hecho aparentemente delictivo). Así, afirma que en el delito de fraude procesal lo que determina quién puede constituirse en actor civil no es la tipicidad del delito sino la producción de un daño indemnizable.

I. Introducción

Mediante auto de calificación de recurso de casación de fecha 5 de octubre de 2018, la entonces Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, que tuvo como ponente a Figueroa Navarro, declaró nulo el concesorio emitido por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura y, por lo tanto, inadmisible el recurso de casación interpuesto por Carlos Alberto Gómez de la Torre contra la Resolución emitida por la referida Sala de Apelaciones que, por mayoría, revocó la Resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura que declaró tener por constituido como actor civil al recurrente en la investigación preparatoria seguida contra Medardo López García por el delito de fraude procesal y, reformándola, lo excluyó del proceso penal[1].

Como puede verse, la decisión que se llevó en casación a la Corte Suprema había sido muy discutida por los jueces de las instancias inferiores, pues el juez de la investigación preparatoria y un juez superior estaban de acuerdo con la constitución como actor civil, mientras que dos jueces superiores negaron esta posibilidad. El tema concretamente debatido y que se le propuso a la Corte Suprema para su dilucidación en uso de sus facultades de uniformización de la jurisprudencia, fue la **posibilidad de que la parte procesal afectada por un delito de fraude procesal pueda constituirse en actor civil dentro del proceso penal**.

Dado que la Corte Suprema emitió un auto de calificación de recurso de casación declarando inadmisible el recurso de casación excepcional presentado por la defensa de Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell, lo lógico sería pensar que esta decisión se amparó en la discreción de la Corte Suprema, en el sentido de no considerar necesario tratar el tema propuesto para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial (artículo 427, inciso 4 del CPP de 2004). Sin embargo, si uno lee el auto antes referido se encuentra con la sorpresa de que la entonces Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema no

[1] Debo hacer el *disclosure* de que ejercí la defensa procesal del denunciante Carlos Alberto Gómez de la Torre.

desestima la casación porque el tema planteado no merezca un desarrollo jurisprudencial, todo lo contrario, lo que hace es entrar en el tema de fondo y pronunciarse explícitamente sobre si la parte afectada por el delito de fraude procesal puede constituirse en actor civil. En efecto, la Corte Suprema dice textualmente en su decisión de inadmitir la casación lo siguiente:

> [S]in embargo, en el delito de fraude procesal, por principio de legalidad, solo el funcionario o servidor público es el sujeto pasivo de la acción. De ahí que si el recurrente sostiene haber sido perjudicado por habérsele interpuesto una querella que le ocasionó gastos por la suma de veintiocho mil setecientos treinta y ocho soles con veinte céntimos, ello no implica, *per se*, que sea perjudicado en el delito de fraude procesal, en tanto el tipo penal exige que el sujeto pasivo sea un sujeto especial (funcionario o servidor público), que tiene abierta la posibilidad de plantear una demanda en la vía civil por responsabilidad extracontractual a fin de que pueda ser resarcido, si el caso lo amerita, por los daños ocasionados. Por tanto, la casación planteada ha de ser desestimada.

Como puede verse, el auto bajo comentario entra a discutir la problemática planteada, concluyendo que la parte procesal afectada no puede constituirse en actor civil del delito de fraude procesal.

Podría decirse que, en tanto al final es la misma Sala Penal de la Corte Suprema la que tendría que decidir sobre el carácter fundado o no de la casación, no habría ningún problema en que directamente decida el tema en el auto de calificación. Tal proceder no solo trastoca el orden del trámite que debe seguir el proceso recursal de la casación penal, sino que genera una afectación al derecho de defensa, pues si hubiese admitido la casación, entonces habría tenido lugar una audiencia de casación, en la que la defensa del recurrente habría podido intervenir y expresar los fundamentos de su recurso. Si la entonces Segunda Sala Penal de la Corte Suprema era de la opinión de que la casación no ameritaba un desarrollo de la doctrina jurisprudencial, simplemente lo debió declarar así y no entrar, por el contrario, a establecer una opinión sobre el tema planteado. Los jueces supremos son los mejores magistrados del país, pero eso no los hace inmunes al error, como ha sucedido, en mi opinión, en el presente caso.

II. El actor civil en el proceso penal: el perjudicado por el delito

La realización de un delito no solo legitima la imposición de una sanción penal, sino que puede dar lugar a la obligación de indemnizar por los daños producidos. En este sentido, la conducta delictiva, en cuanto suceso lesivo, constituye también un hecho civilmente relevante que autoriza al perjudicado a exigir el pago de una reparación civil[2]. El camino regular para hacer efectiva la pretensión civil derivada del ilícito penal sería iniciar el proceso civil, en donde el juez civil determinará el daño producido y establecerá una reparación acorde con dicho daño. Sin embargo, evidentes razones de economía procesal aconsejan ofrecer un modelo procesal en el que ambas pretensiones (penal y civil) se solventen en un mismo proceso (el proceso penal), evitando de esta forma el denominado "peregrinaje de jurisdicciones"[3].

---

[2] Véase, García Cavero (2019, p. 1125)

[3] Véase, así, Silva Sánchez (2001, p. 2) e, igualmente, Gálvez Villegas (2016, p. 315)

En las legislaciones penales modernas se sigue el modelo conocido como *action civile*, en el que se reconoce la posibilidad de que el perjudicado se pueda constituir en el proceso penal como actor civil y exigir ahí el pago de la reparación civil[4]. El que ambas pretensiones se puedan dilucidar en un mismo proceso tiene varias incidencias, como la utilización de la misma base fáctica (siquiera parcial), la adaptación de las reglas de la responsabilidad civil a las particularidades del hecho lesivo (por ejemplo, el plazo de prescripción) o la repercusión de la reparación del daño en la determinación de la pena[5]. Sin embargo, debe precisarse que esta unificación de pretensiones en un mismo proceso no implica que la acción penal se identifique con la acción civil, pues ambas pretensiones mantienen plenamente su independencia normativa.

La reparación civil puede exigirse respecto de cualquier delito que haya generado daños o perjuicios[6]. Si bien tanto la pena como la reparación civil derivada del delito comparten, al menos parcialmente, un mismo presupuesto (la realización de un hecho fáctico que, desde cada uno de los ordenamientos sustantivos, es ilícito), no hay duda de que regulativamente responden a criterios completamente distintos. Cada una de estas consecuencias jurídicas del delito valora el hecho desde su propia perspectiva, lo que se explica por el distinto fundamento del que parten. Así, mientras la pena se impone con la finalidad de mantener la vigencia de la norma culpablemente infringida, la reparación civil derivada del delito se centra en la función de reparar el daño provocado por la conducta penalmente investigada[7]. Esta distinción de fundamentos se aprecia claramente en la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, en donde señala textualmente lo siguiente:

> Así las cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse con 'ofensa penal' -lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente.

La figura jurídica de actor civil se encuentra reconocida en el artículo 98 del Código Procesal Penal. Lo que determina tal calidad, como es fácil deducir, es el perjuicio producido por el hecho penalmente investigado, no la titularidad del bien jurídico. Por el contrario, el agraviado del delito es, conforme al artículo 94 del CPP, el directamente ofendido por este (titular del bien jurídico) o el perjudicado por las consecuencias del mismo. Si el ofendido sufre además algún perjuicio efectivo puede constituirse en actor civil en el proceso penal; si alguien que no es el ofendido, resulta también perjudicado por el delito, podrá igualmente constituirse en actor civil[8]. Lo que sustenta la legitimidad de una persona para pedir su constitución como actor civil en el proceso penal no es la titularidad del bien jurídico afectado o protegido, sino el perjuicio que le ocasiona la conducta que tendría la calidad de un delito.

En el caso de los delitos contra la Administración Pública o contra la administración de justicia, no hay duda de que el ofendido es el Estado y, por lo tanto, pueda este constituirse

---

[4] Véase, Roig Torres (2000, p. 138, nota 98)
[5] Véase, con mayor amplitud, ibídem, p. 138 y ss
[6] Véase, así, Alastuey Dobón (1998, p. 420)
[7] Véase en este sentido, García Cavero, (2019, p. 1126). Sobre el distinto fundamento de la pena y la reparación civil, Roig Torres (2000, p. 119) y Guillermo Bringas (2011, p. 41)
[8] En este sentido, García Cavero (2019, p. 1141)

en actor civil, si la conducta delictiva le produce efectivamente un perjuicio. Sin embargo, si con la realización de uno de estos delitos se perjudica a un particular, no hay ninguna razón para no considerarlo como agraviado y, por lo tanto, quede este habilitado para pedir su constitución como actor civil en el proceso penal. Por poner un ejemplo: si el funcionario público realiza un delito de abuso de autoridad, no hay duda de que el particular afectado por el acto arbitrario del funcionario público deberá ser considerado agraviado del delito y, por lo tanto, podrá solicitar su constitución como actor civil en el proceso penal. Negar esta posibilidad con el argumento de que el titular del bien jurídico es el Estado, constituye un desconocimiento manifiesto de la naturaleza de la acción civil y de las condiciones para su ejercicio en el proceso penal.

III. La decisión contenida en el auto de calificación de recurso de casación de fecha 5 de octubre de 2018

En el caso concretamente analizado, si bien la calidad de titular del bien jurídico protegido por el delito de fraude procesal recae sobre el Estado (concretamente, sobre el Poder Judicial), no puede desconocerse que también pueden existir perjudicados por las consecuencias del acto delictivo. El artículo 98 del CPP establece, como premisa inicial, que el actor civil es el titular de la acción reparatoria y precisa que esta acción solo puede ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito. No se discute que el Estado pueda ser agraviado por la comisión del fraude procesal, ya que es el órgano jurisdiccional al que van dirigidos los medios probatorios manipulados por parte del imputado con la finalidad de inducirlo a error, pero el artículo 98 del CPP no restringe la legitimidad para ejercer la acción civil en el proceso penal al resarcimiento de daños para el ofendido o titular del bien jurídico protegido.

El tenor de la norma procesal es claro al establecer que la acción civil en el proceso penal puede ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito. No siempre se consolidan en una misma persona la calidad de ofendido y de perjudicado, siendo posible que se trate de sujetos diferentes, uno directamente ofendido en su bien jurídico y el otro afectado en su patrimonio, pero es el perjuicio lo que legitima el ejercicio de la acción resarcitoria y habilita al perjudicado a pedir su constitución como actor civil en el proceso penal. Por ende, que el Estado sea el agraviado en un proceso penal por tratarse del ofendido, no excluye que un particular afectado patrimonialmente pueda constituirse como actor civil en dicho proceso. De otro modo, se desnaturalizaría la acción civil y su finalidad resarcitoria para aquel que, sin ser el directamente ofendido, resulte perjudicado con daños producidos por el hecho delictivo.

Lo hasta ahora señalado se corresponde, por otra parte, con la doctrina jurisprudencial establecida en el Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116, la cual, de modo contrario a lo resuelto por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema dispuso que el actor civil sea también el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil dentro de un proceso penal; es decir, es quien ha sufrido los daños producidos por la comisión del delito. En ninguna parte del citado Acuerdo Plenario se dispone que solamente el directamente ofendido o titular del bien jurídico protegido pueda constituirse en actor civil, por el contrario, este hace mención al artículo 98 del CPP, afirmando que debe tenerse como premisa inicial que actor civil es aquel titular de la acción reparatoria, la cual será ejercitada por el perjudicado por el delito. El Acuerdo Plenario señala expresamente, en su considerando número dos, que actor civil es el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil dentro del proceso penal. Es decir, le queda claro a la Corte Suprema que

actor civil es quien ha sufrido en su esfera patrimonial los daños producidos por la comisión del delito, con independencia de si es el titular del bien jurídico protegido por el delito o simplemente un perjudicado por las consecuencias del delito.

Lo que resulta paradójico es que la Resolución bajo comentario en su **considerando noveno** diga exactamente lo señalado en el párrafo anterior. Así textualmente indica:

> Ahora bien, en cuanto a la constitución del actor civil, el Acuerdo Plenario número 5-2011/CJ-116, del seis de diciembre de dos mil once, ha definido conceptualmente lo que es un actor civil (fundamento jurídico décimo primero) precisando que: se define al actor civil como aquella persona que puede ser el agraviado por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo.

Sin embargo, en el **considerando décimo segundo**, hace un giro inexplicable en la motivación de su decisión, pues sostiene que "en el delito de fraude procesal, por principio de legalidad, solo el funcionario o servidor público es el sujeto pasivo de la acción". Y luego concluye su contradictorio razonamiento con la siguiente afirmación: "ello no implica, *per se*, que sea perjudicado en el delito de fraude procesal, en tanto el tipo penal exige que el sujeto pasivo sea un sujeto especial (funcionario o servidor público)". Como premio consuelo, la Corte Suprema dice que la parte procesal perjudicada por el delito de fraude procesal tiene abierta la posibilidad de plantear una demanda en la vía civil por responsabilidad extracontractual a fin de que pueda ser resarcido, si el caso lo amerita, por los daños ocasionados.

La decisión de la entonces Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en la Casación N° 785-2018-Piura es, a todas luces, errónea. Lo es en lo procedimental, pues la declara inadmisible por medio de una desestimación de fondo. La Sala Penal debió, en todo caso, sostener que el tema no ameritaba un desarrollo de la doctrina jurisprudencial, nada más. Pero su falta de acierto más grave tiene lugar en el plano de su argumento de fondo, al que no debió entrar como se acaba de decir, pues confunde la calidad de ofendido (titular del bien jurídico) con la calidad de perjudicado (el que sufre un perjuicio por el hecho aparentemente delictivo). En el delito de fraude procesal lo que determina quién puede constituirse en actor civil no es la tipicidad del delito (sujeto pasivo solamente puede serlo un funcionario público), sino la producción de un daño indemnizable. En nuestro sistema procesal actual puede suceder incluso que la conducta lesiva no llegue a determinarse como delito y, aun así, dar lugar a la imposición de una reparación civil. Nuevamente, lo decisivo no es la titularidad del bien jurídico o la calidad de sujeto pasivo del delito, sino el perjuicio recibido como consecuencia del hecho investigado como delito, y en esta oportunidad la Corte Suprema no ha tenido lo suficientemente clara esta básica distinción.